

1501099-85.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... lhe pertenciam, correspondendo ao lucro do tráfico de drogas. Alegou que na ocasião anterior à sua prisão estava desempregado e passando por dificuldades financeiras, tendo se envolvido com o tráfico a menos de uma semana. Revelou ser usuário de cocaína e maconha e que já teve passagem na Vara da Infância por tráfico de drogas e como usuário.

O próprio réu se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, .

Centro - CEP 12020-070, Taubaté-SP

Fone: (12) 3631-3040 - E-mail: taubate1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501099-85.2021.8.26.0618 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501099-85.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Réu

Justiça Pública

Natanael dos Santos Barbosa

Réu Preso

Vistos.

Natanael dos Santos Barbosa foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de agosto de 2021, por volta das 07h45min, na Rua Messias Guedes Moreira nº 23, bairro São Gonçalo, nesta cidade e comarca de Taubaté, trazia consigo e guardava, para fornecimento e entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, a título de comércio, quatro porções de cocaína, pesando cerca de 7,84g, e dez porções de maconha, pesando cerca de 24,34g, substâncias entorpecentes determinadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Descreve a denúncia que, em razão de investigação a respeito de crime de homicídio tentado, foi expedido pela Vara do Júri desta comarca, nos autos nº 1518774-40.2021.8.26.0625, mandado de busca e apreensão para a residência do réu. Policiais civis para lá se deslocaram, onde apresentaram o mandado aos moradores da casa, sendo autorizada a entrada deles no local. Em busca pela residência, encontraram o réu no quarto dele. Em sua posse, guardados no interior do bolso de uma bermuda, estava um embrulho contendo quatro pinos de cocaína e outro embrulho contendo dez porções de maconha, além da quantia de R\$ 248,00 em dinheiro. Indagado, o réu assumiu a propriedade das drogas aos policiais, alegando que elas e o dinheiro seriam o "lucro" por ele obtido com o tráfico de entorpecentes, realizado para

sustentar o seu vício. Foi dada voz de prisão ao réu, sendo ele conduzido à Delegacia de Polícia (fls. 81/82).

Recebida a denúncia, em 31 de agosto de 2021 (fls. 86/88), o réu foi citado (fls. 102) e apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 116).

Saneado o processo (fls. 117/119), e assentada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, em atendimento à determinação constante do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 139/140), realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que se procedeu à inquirição das testemunhas do rol acusatório, comuns à defesa, e ao interrogatório do réu, seguindo-se a apresentação de alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos em que proposta. Ressaltou que as circunstâncias dos fatos indicam que as drogas se destinavam ao tráfico, de forma que o vício em seu uso não afasta a imputação. No que atine à dosimetria, postulou o arbitramento das penas-base nos mínimos legais; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem redução das penas aquém do piso legal, nos termos da Súmula 231 do STJ; a aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com redução das penas no patamar legal máximo ante a pequena quantidade de drogas apreendidas e a atitude colaborativa do réu, não obstante o seu envolvimento com o tráfico de drogas enquanto menor; a fixação do regime inicial aberto, convertendo-se a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Por fim, pugnou seja decretado o perdimento do valor apreendido em favor da União.

A Defesa manifestou sua concordância com as postulações do Ministério Público, aguardando a prolação de sentença nos termos requeridos.

A audiência foi realizada por meio de teleconferência, mediante utilização da plataforma Microsoft Teams, e a gravação foi posteriormente salva no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 145/146).

É o relatório.
Decido.

O réu estava sendo investigado por eventual envolvimento em crime de tentativa de homicídio e por essa razão, nos autos nº 1518774-40.2021.8.26.0625, da Vara do Júri desta Comarca de Taubaté, houve determinação para realização de busca e apreensão em sua residência (cópia do Mandado de Busca e Apreensão a fls. 18/19).

Os policiais civis Fernando Salles Valério Junior e Felipe Reis de Matos foram encarregados do cumprimento do mandado de busca e apreensão, em apoio à operação dirigida pelo setor policial de investigação de homicídios, e apresentaram narrativas uníssonas na fase policial (fls. 02 e 03, respectivamente) e em juízo, quando melhor detalharam as circunstâncias da diligência. Descreveram que para cumprimento do mandado de busca e apreensão foram à residência do réu no período da manhã e, após cientificarem os moradores a respeito do teor do mandado, efetuaram buscas no imóvel. Enquanto uma equipe se dirigiu à frente da casa, os policiais foram aos fundos do imóvel, onde encontraram o réu e seu irmão mais novo em um quarto. O réu estava deitado; foi acordado e, indagado sobre a existência de algum ilícito no local, de pronto informou sobre a droga no bolso traseiro da bermuda que vestia. Em revista pessoal o PC Fernando localizou, na referida vestimenta, quatro pinos de cocaína, dez invólucros plásticos de maconha e a quantia de R\$248,00 em dinheiro. Indagado, o réu confirmou que a droga lhe pertencia e seria destinada à venda, e afirmou que as drogas e o dinheiro correspondiam ao seu lucro pela venda de drogas. Assim sendo, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Ambos os policiais mencionaram que o réu não apresentou resistência, adotando postura colaborativa, inclusive com prontidão e a todo momento, segundo o PC Fernando.

O réu, que já havia confessado a autoria da conduta delitiva aos policiais civis que procederam à sua abordagem, também a confessou à autoridade policial ao ser interrogado quando da lavratura do flagrante, dizendo que a venda de drogas tinha a finalidade de sustentar o seu próprio vício (fls. 04).

Nesta fase judicial mais uma vez o réu confessou a prática delitiva, asseverando que as drogas e o dinheiro apreendidos lhe pertenciam, correspondendo ao lucro do tráfico de drogas. Alegou que na ocasião anterior à sua prisão estava desempregado e passando por dificuldades financeiras, tendo se envolvido com o tráfico a menos de uma semana. Revelou ser usuário de cocaína e maconha e que já teve passagem na Vara da Infância por tráfico de drogas e como usuário.

O próprio réu se contradisse em juízo ao afirmar a incipiência de seu envolvimento com o tráfico na época de sua prisão, já que posteriormente informou o registro da prática de atos infracionais durante a menoridade, correspondentes justamente ao tráfico de drogas. A corroborar a narrativa, o PC Fernando informou que o réu é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, registrando ocorrências por esse crime em sua menoridade, o que restou demonstrado pela Certidão de Distribuições Criminais acerca de Ações da Infância e Juventude Infracional, de que constam cinco registros a respeito do réu (fls. 41).

Não obstante, a sinceridade de sua reiterada narrativa a respeito da destinação ao tráfico das drogas encontradas consigo durante a diligência policial deve ser prestigiada.

Não descaracteriza o tráfico a alegação do réu de que o lucro obtido com a venda de drogas era destinado ao sustento de seu próprio vício, uma vez que o próprio réu confessou, ao ser abordado pelos policiais, e às autoridades policial e judicial, que estava realizando o tráfico ilícito de entorpecentes e que o dinheiro encontrado com ele era resultado de tal prática. Além disso, não são incompatíveis as condições de usuário e de traficante de drogas.

Bem provada a autoria do delito, observa-se que o réu foi preso em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante Delito a fls. 01) e a respeito da conduta foi lavrado Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), registrando-se a apreensão, em seu poder, de R\$ 248,00 em dinheiro (comprovante de depósito judicial a fls. 70 e 75), além de quatro pinos que continham cocaína e dez invólucros plásticos transparentes que continham maconha (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 08 e Fotografia a fls. 38).

No exame preliminar não se chegou a resultado conclusivo sobre a natureza do material contido nos pinos apreendidos, "devido à complexidade da análise, incompatível com a rapidez demandada pelos exames de constatação" (Laudo de Constatação Provisória de Entorpecente a fls. 09/11). No exame definitivo (Laudo de Exame Químico-Toxicológico a fls. 112/114) não se identificou, nos pinos, a presença de cocaína, mas apenas de 0,9g de cafeína, lidocaína e tetracaína.

Tais substâncias, por si sós, conquanto utilizadas para a preparação de entorpecentes, não são consideradas entorpecentes de uso proscrito.

De outra parte, porém, tanto preliminarmente, como definitivamente, identificou-se que o remanescente do material apreendido em poder do réu tratava-se, efetivamente, de 24,34g de maconha, pois "foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), que se encontra descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017)".

Nesse contexto, comprovado o caráter entorpecente da substância e sua destinação ao tráfico, confessada pelo réu, bem como dos demais materiais apreendidos, deve ele ser condenado.

Procedo a seguir à dosimetria das penas, com atendimento ao disposto no art. 68 do Código Penal.

Em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal e àquelas enumeradas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, observa-se que o réu não registra antecedentes (Folha de Antecedentes a fls. 109/110 e Certidão Estadual de Distribuições Criminais a fls. 111), bem como foi apreendida quantidade mínima de droga - 24,34g de maconha -, que estava dividida em poucas porções, o que não justifica a exacerbação das penas-base nesta fase de fixação, sendo arbitradas nos mínimos legais, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Incidem duas atenuantes: confissão (Código Penal, art. 65, inc. III, 'd'), pois constituiu elemento de convicção (STJ, Súmula 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal), assim como foi integral relativamente à prática delitiva (STJ, Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio), e menoridade relativa (Código Penal, art. 65, inc. I), pois o réu era comprovadamente menor de 21 anos ao tempo dos fatos (documento de identidade a fls. 14).

Ambas não importarão, todavia, em alteração das penas, ante a impossibilidade de que atenuantes as reduzam aquém de sua cominação abstrata mínima, em que já foram arbitradas (STJ, Súmula 231: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

Não há agravantes a considerar.

Tem aplicabilidade à hipótese o privilégio preconizado na Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º, pois não há evidências de que o réu integre organização criminoso ou de que se dedique a atividades criminosas com habitualidade, eis que, como já referido, é primário e não registra qualquer antecedente criminal, a despeito dos registros quando menor, tendo sido abordado em cumprimento de mandado de busca por investigação de crime de natureza diversa e não por força de notícias que denotassem a ciência por terceiros sobre seu envolvimento com a traficância; além disso, foi encontrado com quantidade mínima de entorpecentes, adotando atitude colaborativa com os policiais civis e não impondo qualquer óbice aos trabalhos, tudo a denotar que sua personalidade permite lhe sejam concedidas benesses legais, motivos que fazem incidir a causa especial de diminuição de penas, em seu patamar máximo.

Frente ao exposto, reduzo as penas cominadas de dois terços e, à ausência de outras causas de modificação, torno-as definitivas em 1 anos e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da vedação constante da parte final do § 4º do art. 33 Lei nº 11.343/06, e suspensa pela Resolução nº 5, de 16/02/2012, do Senado Federal, a execução da expressão vedada a conversão em penas restritivas de direitos constante do mesmo dispositivo, inexistente óbice legal à substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade, a qual não suplanta quatro anos.

Atendidos os requisitos dos incisos I a III do art. 44 do Código Penal, de acordo

com a parte final do § 2º do mesmo dispositivo legal substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social e sede nesta Cidade, a critério do Juízo sucessivo da Execução (Código Penal, art. 45, § 1º), e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, igualmente a critério do Juízo sucessivo da Execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, pelo prazo desta última (Código Penal, art. 46, §§ 1º a 4º), devendo ser observada a respeito, oportunamente, a detração penal, já que o réu foi preso em flagrante e permanece recolhido ao cárcere desde 9 de agosto de 2021.

A respeito da fixação do regime inicial de cumprimento de pena para a hipótese de conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade (Código Penal, art. 44, § 4º), observa-se que o STJ, ao julgar a Questão de Ordem na Pet. 11.796-DF, afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 600), na sessão de 23/11/2016 firmou a tese de que “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo” (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 29/11/2016).

Também a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (denominado Pacote Anticrime), incluiu o § 5º no art. 112 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), que trata da progressão de regimes durante a execução das penas privativas de liberdade, o qual passou a dispor que “não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.

À vista do exposto, a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser feita com base nas normas gerais estabelecidas no Código Penal (e não se olvidando do quanto determinado no Habeas Corpus nº 596.603, Rel. o Ministro Rogério Schietti Cruz), razões pelas quais, atendidos os pressupostos legais, fixo o regime inicial aberto de cumprimento de pena para a hipótese de conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade (Código Penal, art. 33, § 2º, 'c').

Não havendo nos autos informes específicos sobre a situação econômica do réu (Código Penal, art. 60, e Lei nº 11.343/06, art. 43), o valor unitário do dia-multa deverá corresponder ao mínimo legal, de um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente desde essa ocasião segundo os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

Como efeito desta sentença condenatória determino a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido em poder do réu, que ele próprio declinou ter origem ilícita, sendo produto do narcotráfico (Código Penal, art. 91, inc. II, 'b', e Lei nº 11.343/06, art. 63, inc. I).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Natanael dos Santos Barbosa à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser paga a entidade pública ou privada com destinação social e sede nesta Cidade, e em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da condenação, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação (observando-se a detração penal); condeno-o, igualmente, à pena pecuniária de 166 dias-multa, com cálculo da unidade destes no piso legal, por incursão no art. 33, caput, c.c. o respectivo § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Conquanto não haja nos autos pedido expresso de gratuidade da justiça, presume-se, na hipótese, a hipossuficiência do réu, em face de sua solicitação, ao ser citado, de nomeação da Defensoria Pública para a sua assistência (fls. 102), além de sua

declaração em juízo a respeito de dificuldades financeiras. Por essas razões, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual nº 11.608/2003, art. 4º, §9º), mas determino a suspensão da exigibilidade da verba enquanto perdurar a insuficiência de recursos que justifica lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita (anote-se); ao cabo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, remanescendo a hipossuficiência financeira, poderá ser reconhecida sua inexigibilidade, o que fica a cargo do Juízo das Execuções.

O réu foi preso em flagrante e permaneceu recolhido ao cárcere no decorrer do processo porque se faziam presentes os requisitos da prisão preventiva. Presentemente, condenado a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, não há razoabilidade em que seja mantida sua custódia, pois importaria na permanência do réu em regime fechado, mais gravoso do que aquele imposto por esta sentença, a caracterizar desproporcionalidade.

Frente ao exposto, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Ao trânsito em julgado:

i) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados;

ii) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (para os fins da Constituição Federal, art. 15, inc. III);

iii) intime-se o réu para pagamento da multa penal imposta, no prazo de dez dias (Código Penal, art. 50, caput, e Código de Processo Penal, art. 686);

iv) oficie-se à Senad, encaminhando-lhe informação sobre o valor de R\$ 248,00 em dinheiro, declarado perdido em favor da União (Lei nº 11.343/06, art. 63, §4º), objeto do auto de fls. 08 e do depósito de fls. 70 e 75.

Publique-se. Intimem-se.

Taubaté, 03 de fevereiro de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballesterio
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA